

1501941-58.2021.8.26.0297

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO ANTONIO CAMARGO DANTAS

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... de cumprir pena, recentemente, por tráfico de drogas, o réu continuou se dedicando ao tráfico, valendo-se de ponto estratégico para a venda de substâncias entorpecentes no bairro Vila União, local conhecido como reduto de tráfico na cidade, inclusive com frequentes ocorrências envolvendo crianças e adolescentes, e que fica próximo à FATEC, Poupatempo, unidades de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

1ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501941-58.2021.8.26.0297 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501941-58.2021.8.26.0297

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2328961/2021 - 01º D.P. JALES, 21748650 - 01º D.P. JALES, 4410/21/227 - 01º D.P. JALES, 2328961 - 01º D.P. JALES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR PAULO BORGES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ANTONIO CAMARGO DANTAS

Vistos.

VITOR PAULO BORGES foi denunciado como incurso no artigo 33, c.c artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, porquanto, em conformidade com os termos vertidos na exordial acusatória, no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 8h20, nas proximidades da Avenida Francisco Jales, nº 48, defronte à Padaria Lisboa, na Vila União, nesta cidade e Comarca de Jales, nas mediações de estabelecimentos de ensino e hospitalares, praças públicas, sedes de entidades sociais, culturais e beneficentes, o réu, vulgo "Nenezão", trazia consigo, para fins de tráfico e entrega a consumo de terceiros, uma grande porção de cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de 47,08g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$155,10, em notas e moedas diversas.

Segundo as linhas tracejadas na denúncia, após ter sido colocado em liberdade,

depois de cumprir pena, recentemente, por tráfico de drogas, o réu continuou se dedicando ao tráfico, valendo-se de ponto estratégico para a venda de substâncias entorpecentes no bairro Vila União, local conhecido como reduto de tráfico na cidade, inclusive com frequentes ocorrências envolvendo crianças e adolescentes, e que fica próximo à FATEC, Poupatempo, unidades de saúde do Consirj, além de diversas igrejas, escolas e praças.

Consta, ainda, da prefacial acusatória, que, no dia dos fatos, o réu trazia consigo uma porção grande de crack, com finalidade de comercialização a terceiros, e, por sua vez, que, enquanto saía da Padaria Lisboa, avistou policiais militares, mudando repentinamente de direção, chamando a atenção dos agentes públicos, que o abordaram.

Nos termos da incoativa, foram realizadas buscas pessoais, e, a seu turno, foi encontrado com o réu uma porção de crack, a qual seria dividida em dezenas de pequenas porções, além de R\$ 155,10, em notas e moedas diversas, advindos da venda de substâncias entorpecentes.

Colhe-se, ainda, da denúncia, que, em solo policial, o réu confirmou a propriedade das drogas.

Eis, em compêndio, os termos da denúncia (fls.115/118).

Realizada audiência de custódia, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão cautelar (fls.119/121). O réu foi notificado dos termos da denúncia (fls.236), de sorte que, no comenos oportuno, por intermédio de sua defensora, ofereceu a abalizada defesa preliminar (fls.154/157).

Sem embargo dos argumentos expendidos, a denúncia foi recebida no dia 01 de abril de 2022, aprazando-se, assim, data para a realização da audiência de instrução e julgamento (fls.159/162 e 170/171).

Na data aprazada, houve a colheita da prova oral, ouvindo-se, na oportunidade, três testemunhas. O réu, por sua vez, foi ouvido em sede de interrogatório, por intermédio do qual exerceu a sua autodefesa (fls.263/265).

Ao cobro da instrução, houve o oferecimento dos abalizados memoriais, iniciando-se, como sói ocorrer, pelo Ministério Público, o qual, com o empréstimo da pena de seu Ilustre Promotor de Justiça, pugnou pelo acolhimento da pretensão acusatória, com a conseguinte condenação do réu, aventando, no ponto, que a materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls.58/59), rebatimento fotográfico (fls.60/61), laudo pericial de constatação (fls.64/66) e a apreensão da quantia de R\$155,10, bem como a autoria, considerando o conjunto probatório lógico, firme e robusto.

Ao incursionar sobre a dosimetria da pena, na primeira fase, pugnou pela exasperação da pena base, considerando-se, no ponto, a alta periculosidade da substância apreendida, a saber, o crack, e, ainda, pela exasperação da pena, acima do mínimo legal, em razão de o réu ser portador de maus antecedentes.

Na segunda fase, manifestou-se pela existência da agravante da reincidência, apontando ser o réu reincidente específico.

De sua vez, na terceira fase, manifestou-se pela causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas, baseando-se no laudo pericial do local do fato (fls.167/169), e, outrossim, pelo afastamento da causa de diminuição da pena, por tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em razão da presença de maus antecedentes e da multirreincidência do réu.

Em linha de remate, propugnou pela fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, averbando, por sua vez, ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.238/247).

A defesa, ao reverso, palmilhando senda visceralmente oposta, bateu-se pela absolvição do réu, averbando, em escorço, que nenhuma das provas colhidas são capazes de confirmar a autoria e a materialidade do suposto crime de tráfico praticado pelo réu, batendo-se, por sua vez, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Alteou, a seu turno, que o órgão acusatório pretende a condenação do acusado amparado no depoimento de um policial militar que emitiu opinião pessoal sobre os fatos, com intuito acusatório, e não narrou nenhuma situação de traficância.

Asseverou, ainda, que o depoimento do policial ficou em desarmonia com o conjunto probatório, visto que os depoimentos prestados pelas testemunhas atestaram a dependência química do réu e o seu exercício de trabalho lícito.

Pontuou, a seu turno, que o policial ouvido em pretório não presenciou nenhuma atitude do réu relacionada à mercancia de drogas, e, outrossim, que o réu foi apenas abordado na posse de dinheiro e do entorpecente, consignado, ainda, que o policial mencionou ter feito a abordagem do réu em outras ocasiões e que não teria encontrado nada de ilícito.

Afirmou, em adição, que nenhum outro apetrecho sugestivo de mercancia foi encontrado no local, como balança de precisão ou celular, averbando, a seu turno, que o numerário apreendido advinha do trabalho lícito do réu.

Esgrimiou, a sua vez, que a quantidade de droga apreendida não se revelou em quantidade expressiva, e, ainda, que inexistiram diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância, pontuando, outrossim, que a autoridade policial e o Ministério Público concluíram que o réu seria traficante em razão da localidade em que foi preso em flagrante, com base em indícios.

Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, averbando, a sua vez, que o réu afirmou ser usuário de drogas de longa data, e, ainda, que esta alegação foi confirmada pelas testemunhas ouvidas em juízo, pontuando, outrossim, que a quantidade de droga era compatível com o consumo próprio.

Ao incursionar sobre a dosimetria da pena, pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal, averbando, ainda, a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, pugnano, outrossim, pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas, visto que o réu não promovia a distribuição da droga e nem se valia dos frequentadores locais.

De sua vez, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, requereu a fixação de regime menos gravoso, e, ainda, que seria cabível o regime semiaberto (fls.249/262).

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

A pretensão acusatória não merece ser agasalhada.

A apreensão da droga é inconteste, conforme se conclui do auto de exibição e apreensão de fls. 58/59, laudo de constatação provisória de fls. 64/66 e laudo de exame químico toxicológico de fls.126/128.

Entrementes, a quadra indiciária que escorou o cerceio cautelar do réu, a rigor, não foi corroborada pela prova judicializada, na medida em que não restou demonstrado o desiderato de mercancia.

Em uma palavra, o cenário inicial que acenava para a perspectiva do tráfico, diante da quadra probatória colhida em juízo, restou absolutamente infirmado.

Da acendrada análise do arquétipo probatório, colhe-se, em compêndio, que a testemunha Cláudio Aparecido Gonçalves, ao prestar seu depoimento em pretório, disse que, na data do fato, estavam em patrulhamento pela Vila União, informando, a seu turno, que se tratava de local conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas, afirmando, outrossim, que o réu, ao avistar a viatura policial, mudou o sentido da sua direção, e, por sua vez, que, por este motivo, fizeram a sua abordagem, informando, ainda, que o réu era conhecido por tráfico de drogas. Relatou, a seu turno, que o réu estava na posse de uma pedra grande de crack, com 47 gramas, além de pouco mais de R\$150,00, em notas trocadas, informando, ainda, que o entorpecente apreendido poderia ser fracionado em outras 150 porções de crack. Disse, ainda, que o local do fato ficava próximo de uma igreja católica, distante de 1/4 do quarteirão, bem como uma escola, chamada FATEC, a dois quarteirões de distância, além de um Posto de Saúde e uma unidade "Poupa Tempo". Informou, a sua vez, que há o consumo de entorpecentes por adolescentes na localidade do fato, informando, outrossim, que existe um "campinho" utilizado por menores para o consumo e venda de entorpecentes. Disse, ainda, que a conduta do réu foi enquadrada como tráfico de drogas em razão do réu ser conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico e, outrossim, em virtude da quantidade de entorpecente apreendida, afirmando ser grande a quantidade de 47 gramas de crack para um usuário, informando, ainda, que um usuário costuma portar pouca quantidade e que a consome de imediato. Confirmou, outrossim, que um usuário de crack costuma sofrer de ansiedade para o consumo da droga e que não tem condições de se organizar para o gerenciamento do consumo em casa. Relatou, por sua vez, que desconhece uma ocupação lícita do réu, afirmando, ainda, que o réu não mencionou que exercia algum trabalho, e, outrossim, que sempre avistava o réu caminhando pela Vila União, nos pontos de tráfico, em dias úteis e horários comerciais. Disse, a seu turno, que o réu costumava frequentar bares na região, citando o mais conhecido "Bar do Shrek". Afirmou, ainda, que o réu declarou que a droga era destinada ao consumo pessoal, negando, por sua vez, que o réu estivesse transportando algum utensílio para o consumo de crack, tal como um cachimbo, além da quantia de R\$155,00 em notas trocadas no bolso. Negou, outrossim, que, na ocasião, o réu estivesse sob aparente efeito de entorpecente, como o crack, afirmando, por sua vez, que o réu apresentava odor etílico. Negou, por sua vez, que o réu tivesse sido avistado comercializando com outra pessoa próxima, negando, ainda, que o réu estivesse portando algum aparelho celular, ou outro instrumento indicativo de tráfico, além da pedra bruta de entorpecente e do dinheiro trocado. Confirmou, ainda, que o réu foi abordado nas demais ocasiões em que foi avistado, e, por sua vez, que somente na data do fato foram localizados entorpecentes em sua posse. Confirmou, a seu turno, que costumam existir muitos usuários de droga no local do fato, informando, ainda, que a Vila União é conhecida como a "cracolândia" de Jales. Afirmou, por sua vez, que teve notícias de o réu ser usuário de maconha, afirmando, outrossim, que, anteriormente, já tinha feito a prisão do réu por tráfico de drogas. Negou, a seu turno, que tivesse conhecimento de o réu ser usuário de crack, ou, ainda, que tivesse notícias neste sentido.

A testemunha Elaine Cristina da Silva Ribeiro Gomes, de sua vez, ao prestar seu depoimento em juízo, disse que conhece o réu e a mãe dele, afirmando, ainda, que conheceu o réu de vista, quando ele e mãe dele saíam para trabalhar, informando, a seu turno, que mora em frente da residência do réu. Disse, ainda, que tem 38 anos de idade e que conhece o réu desde os seus 17 anos de idade, afirmando, outrossim, que tem conhecimento de o réu ser usuário de drogas, informando, a seu turno, que a mãe dele já promoveu diversas tentativas de internações dele, sem sucesso. Relatou, a seu turno, que o réu trabalhava em uma plantação de laranjas, afirmando que o via sendo transportado pelo veículo que conduzia os trabalhadores rurais. Negou, a sua vez, que o réu lhe tivesse oferecido drogas, ou, ainda, que o tivesse visto

vendendo drogas. Afirmou, ainda, que a mãe do réu informava que ele usava crack em uma lata e, por sua vez, que a mãe dele a consultou sobre locais de internação, quando a indicou a “Clínica do Zen”, informando, outrossim, que a mãe do réu nunca conseguiu uma internação. Disse, a seu turno, que, um dia antes de o réu ser preso, ele tinha saído para trabalhar no laranjal, informando, ainda, que desconhece o motivo de o réu não ter ido ao trabalho na data da prisão.

A testemunha Max Sander Faustino de Lima, a seu turno, ao prestar seu depoimento em juízo, disse que conheceu o réu em razão do trabalho no laranjal, quando foi procurado pelo réu pedindo uma oportunidade de emprego, informando, ainda, que o réu estava trabalhando há 5 ou 6 meses em sua companhia, e, por sua vez, que ele nunca apresentou nada ilícito no trabalho. Disse, ainda, que o réu trabalhava das 07 horas da manhã até o término do expediente, na parte da tarde, informando, outrossim, que não viu o réu usando drogas e, por sua vez, que havia comentários de que ele era usuário de drogas. Relatou, a sua vez, que o pagamento do réu era feito semanalmente, às sextas-feiras, e, ainda, que também era feito um pagamento no sábado, em relação ao que era trabalhado durante o sábado. Disse, ainda, que ganhavam em torno de R\$500,00 a R\$800,00 por semana. Afirmou, a seu turno, que teve notícia de o réu ser usuário de entorpecente, do tipo pedra. Relatou, ainda, quando o réu lhe pediu emprego, que foi buscar informações a respeito dele em um bar, e, por sua vez, que lhe disseram que o réu tinha trabalhado há muito tempo e que ele tinha saído da prisão recentemente, e, ainda, que se preocupou em não indicar alguém ao seu encarregado que pudesse macular a sua reputação no local de trabalho.

O réu Vitor Paulo Borges, vulgo “Nenezão”, por seu turno, ao exercer a sua autodefesa, disse que completaria 44 anos de idade no dia seguinte, e, a seu turno, que morava juntamente com a sua mãe, em um lote composto por duas casas, morando nos fundos. Afirmou, ainda, que estava trabalhando como servente, logo que saiu da cadeia, e, outrossim, que, ao término da obra, procurou outro trabalho, quando começou a trabalhar no laranjal, informando, ainda, que estava trabalhando na colheita de laranja há 5 ou 6 meses, aproximadamente. Afirmou, outrossim, que ficou um bom tempo sem usar drogas, após sua saída da prisão, afirmando, ainda, que tinha envolvimento com uma pessoa que era dependente química. Disse, a seu turno, que não se considera uma má pessoa, e, por sua vez, que vem lutando contra o vício há bastante tempo, afirmando, ainda, que fazia uso de crack. Confessou, por sua vez, que, na data do fato, estava na posse do entorpecente que foi apreendido, relatando, ainda, que, nesta data, tinha conhecimento de que o pomar de laranjas havia acabado e que não iria trabalhar naquele dia. Narrou, ainda, que sempre procurou ser discreto em relação ao seu consumo de entorpecente para não perder o seu emprego. Informou, a seu turno, que, na data do fato, tinha ficado sem dormir e, ainda, que, pela manhã, já estava sentindo a abstinência da droga, relatando, por sua vez, que encontrou uma pessoa que lhe ofereceu o entorpecente por R\$300,00. Disse, ainda, que estava dentro de uma padaria, aguardando o seu atendimento, quando foi abordado pelos policiais militares, afirmando, outrossim, que não dificultou a ação deles. Narrou, por sua vez, que foi questionado sobre a destinação da droga, afirmando, ainda, que declarou aos policiais que seria para o seu próprio consumo, e, a seu turno, que os policiais disseram que tinham conhecimento da sua traficância e que encontrariam uma balança em sua residência, ao que negou, reafirmando ser apenas um usuário. Relatou, a seu turno, que, posteriormente, na Delegacia, tomou conhecimento de que os policiais invadiram a sua casa e que não tinham encontrado nada.

Em apertada síntese, os parágrafos encimados espelham os contornos da prova oral.

Ao passar em revista ao acervo probatório, não diviso a presença de quadra probante suficiente ao juízo de segurança necessário ao édito condenatório.

Deveras, a prova não é segura.

Nessa arquitetura, conforme se infere da análise assisada da prova oral colida em juízo, portanto, prova judicializada, porquanto construída sob o pálio do devido processo legal, não é possível afiançar, com a segurança necessária, o desiderato da traficância.

De se ver que, no caso em tablado, o réu não foi pilhado na posse de qualquer ato de mercancia.

Por sua vez, o olhar atento de seu interrogatório, o qual está gravado, demonstra, à saciedade, o seu estado de vulnerabilidade, e os efeitos deletérios do quadro de drogadição em sua vida.

Averbe-se, em adição, que o seu estado de drogadição e, ademais, a sua condição de usuário da substância prosaicamente conhecida como "crack", vieram confirmados por duas testemunhas.

A rigor, demonstrado, sobejamente, o estado de drogadição, e a precarização pessoal do réu em razão do uso de drogas, não se cogita de sua condenação pelo tráfico pela posse da droga, quando não é apontado qualquer ato de traficância.

Sobreleva notar, outrossim, que, em seu interrogatório, o réu, em momento algum, titubeou sobre os fatos, de molde que a sua condenação pelo tráfico, no caso em tablado, a rigor, estaria simplesmente lastreada em seus registros desabonadores, malferindo-se, assim, o direito penal do fato, com o consequente encarecimento do direito penal do autor.

Neste sítio, considerando-se o objeto do processo penal em apreço, a saber: a pretensão acusatória deduzida na denúncia, com imputação certa e determinada, delimitada no tempo e no espaço geográfico, o que importa é a análise de elementos indicativos de traficância, o que, com a devida vênia, não desponta como algo diáfano, ao reverso, os elementos cognitivos somente escoram o reconhecimento de que o réu foi apreendido com a droga, o que, isoladamente, não pode ser conducente do raciocínio de que a droga apreendida era destinada ao tráfico, com esteio em seu passado, notadamente diante de sua vulnerabilidade pessoal, do teor de seu interrogatório, da colheita da prova testemunhal, e da ausência de provas no sentido de que, quando de sua apreensão, estava praticando atos de mercancia.

Não havendo qualquer halo de prova que suporte o reconhecimento da comercialização da droga que o réu trazia consigo, não tendo sido pilhado em atos de tradição, tampouco na companhia de terceiros, diante de seu estado pessoal que pode ser verificado do olhar atento do interrogatório, considerando-se, ademais, os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa, forçoso convir que, no caso em tela, o mosaico probatório não suporta o reconhecimento da traficância, a qual não pode advir do histórico de vida do réu, até porque se há imputações de atos de traficância pretéritos, ao que parece, a sua condição de usuário, também, é indisputável.

O desiderato de mercancia dever ser provado, de molde que vistosamente não pode ser presumido, tampouco pode estar simplesmente calcado em aspectos quantitativos, na natureza da droga e ou nos registros do réu, sob pena de se objetificar a análise do elemento subjetivo reclamado pelo artigo 33 da Lei de Drogas, o qual reclama o escopo de venda, de comercialização.

De fato, o que estrema a configuração do artigo 28, do artigo 33, ambos da Lei de Drogas, indubiosamente, é o elemento subjetivo, na medida em que há absoluta similitude entre determinadas condutas inculpidas nos referenciados artigos.

Havendo dados que suportam a dependência (interrogatório e depoimentos testemunhais), inclusive com menção por uma das testemunhas da preocupação da mãe

do réu e do desejo de interná-lo, não havendo prova de comercialização da droga, a mercancia não pode ser presumida, tampouco intuída, com base em raciocínios indutivos que, ontologicamente, se esteiam nos registros desabonadores do réu, sob pena de, diante da ausência de provas, ser condenado por presunções, com base em seus registros históricos.

Noutras letras, a despeito da quantidade de drogas, de sua natureza, e dos registros do réu, não havendo prova mínima de mercancia, apresentando o réu versão lúcida e coesa, confirmada pelos depoimentos testemunhas e, outrossim, havendo verossimilhança em sua alegações, notadamente ao considerar não somente a sua narrativa, mas, também, o seu estado em audiência, denotativo de sério comprometimento decorrente do uso de drogas, de rigor reconhecer a falência da quadra probatório, nestes autos, acerca da conduta imputada na denúncia.

Em uma palavra, não há prova segura no sentido de que a droga era destinada ao comércio.

Com efeito, a quantidade de droga e a sua natureza, isoladamente, não podem ser conducentes ao reconhecimento do tráfico, o qual deve promanar de sinais externos, como, verbi gratia, apreensão de quantidade em escala industrial, absolutamente incompatível com o consumo, abordagem do réu em atos de tradição, apreensão de valores significativos e injustificados, petrechos e quejandos.

Em casos tais, havendo dúvidas se a droga era, de fato, destinada ao comércio, esta, por força do imperativo constitucional (presunção da inocência), deve ser solvida em prol do réu.

Em uma palavra, se o artigo 28 da Lei de Drogas alude à posse de drogas para o consumo pessoal, por evidente, o desígnio mercantil integra as condutas preconizadas no artigo 33 da Lei de Drogas, devendo, assim, ser provado, de forma satisfatória.

Pontua-se, em acréscimo, que fortes indícios de autoria não são elementos cabais para se romper a baliza da presunção de inocência dentro do standard probatório.

O édito condenatório reclama, a rigor, a presença de um standard probatório que aponte para elementos de convicção que suportem a imputação para além de uma dúvida razoável.

Quadra aqui salientar que, no âmbito do processo penal, o édito condenatório reclama prova para além da dúvida razoável.

Conforme se infere dos autos, a versão segura apresentado pelo réu, em juízo, a rigor, desde o pórtico da persecução penal, foi sustentada, na medida em que, em solo policial, o réu asseverou que adquiriu a droga para o seu consumo (fls.05).

Sobre a prova oral acima transcrita, divisa-se que, a testemunha Elaine Cristina da Silva Ribeiro Gomes, ao ser ouvida, mencionou conhecer o réu, afirmando, outrossim, que tinha conhecimento de o réu ser usuário de drogas, informando, a seu turno, que a mãe dele já havia promovido diversas tentativas de internações dele, sem sucesso.

Negou, a sua vez, que o réu já tivesse lhe oferecido drogas, ou, ainda, que o tivesse visto vendendo drogas.

Disse, a seu turno, que, um dia antes de o réu ser preso, ele tinha saído para trabalhar no laranjal, informando, ainda, que desconhecia o motivo de o réu não ter ido ao trabalho na data da prisão.

A testemunha Max Sander Faustino de Lima, a seu turno, ao prestar seu depoimento em juízo, disse que conheceu o réu em razão do trabalho no laranjal, quando foi

procurado pelo réu pedindo uma oportunidade de emprego, informando, ainda, que o réu estava trabalhando há 5 ou 6 meses em sua companhia, e, por sua vez, que ele nunca apresentou nada ilícito no trabalho.

Disse, ainda, que o réu trabalhava das 07 horas da manhã até o término do expediente, na parte da tarde, informando, outrossim, que não viu o réu usando drogas e, por sua vez, que havia comentários de que ele era usuário de drogas.

Afirmou, a seu turno, que teve notícia de o réu ser usuário de entorpecente, do tipo pedra.

O réu disse, a seu turno, que não se considera uma má pessoa, e, por sua vez, que vem lutando contra o vício há bastante tempo, afirmando, ainda, que fazia uso de crack.

Desvelando-se, assim, a prova oral coligida, conclui-se, de forma heurística, que falecem elementos para o reconhecimento da traficância.

Com efeito, do ponto de vista jurídico, somente se valora aquilo que se encontra documentado no processo, permitindo o exercício do contraditório pelas partes.

Noutras dizes, não se condena com base em presunções, porquanto no processo penal a única presunção que campeia é a presunção da inocência, princípio que, para além de impor toda a prova ao Estado, reclama, outrossim, um dever de tratamento ao réu, de molde que deve ser tratado como inocente, de tal arte que, esta presunção somente deve ceder passo, diante de prova robusta e incontestável.

Para se imputar o tráfico de drogas, imperioso a demonstração do desígnio mercantil.

Com efeito, diante da similitude das ações nucleares que envolvem a posse para consumo pessoal e o tráfico, não se cogita da condenação pela traficância, sem prova segura do escopo de mercantilização.

Por sua vez, sob pena de absoluta ofensa ao princípio da presunção da inocência, com a devida vênia aos entendimentos divergentes, não é ônus do réu a prova de que a droga era destinada ao seu consumo, ao reverso, cabe ao Estado, mediante a atuação de seus órgãos, demonstrar que a droga era destinada ao comércio.

A natureza da droga e a sua quantidade, inexistindo outros significantes, não pode ensejar a presunção do dolo, porquanto o aspecto nodal para configuração do tráfico não é simplesmente a quantidade da droga apreendida, inexistindo outros elementos denotativos da prática do comércio.

Deveras, considerando-se a teoria constitucional do delito, o ponto fulcral, forte no princípio da culpabilidade, é a demonstração segura do desiderato da traficância, descabendo, assim, a absolutização de aspectos objetivos (quantidade e natureza) para a partir destes querer intuir o dolo.

Noutras palavras, a imputação não deve decorrer, exclusivamente, da natureza e da quantidade da droga apreendida, decorrendo, ao reverso, de uma visão holística de todos os significantes que defluem do processo.

Caso fosse possível sopesar, tão-somente, a quantidade de drogas ou a sua natureza, indubitavelmente, haveria o errático procedimento de objetificar o elemento subjetivo, tornando-se prescindível a demonstração do dolo.

Nessa linha de intelecção, cabe ao órgão responsável pela acusação, demonstrar,

satisfatoriamente, com indicativos seguros da base empírica o animus de comercialização da droga apreendida.

Em arremate, aspectos objetivos como quantidade e natureza da droga, em absoluto, alijam a necessidade da demonstração dos elementos cognitivos e volitivos que envolvem o dolo.

Deveras, em linha de remate, de ver-se que, não havendo por ocasião da abordagem, cenário seguro denotativo da mercancia de drogas, na medida em que o réu não foi avistado entregando drogas, mediante contraprestação em dinheiro, nada há a infirmar a sua versão sobre os fatos, notadamente quando desponta como coesa e segura.

Asseverado pelo réu que a droga se destinava ao seu consumo pessoal, com a devida vênua aos entendimentos divergentes, sob pena de restar malferido o princípio da presunção da inocência, conforme gizado, caberia ao Estado demonstrar que a droga se destinava ao comércio, o que, vistosamente não pode ser presumido.

Deveras, a tessitura constitucional não se compraz com presunções em desfavor do acusado, de molde que, no processo penal, não há distribuição de carga probatória, ao reverso, as hipóteses descritas na denúncia devem ser suficientemente comprovadas, alijando-se, assim, qualquer cenário dúbio.

Curial repisar que, considerando-se a similaridade entre as condutas insculpidas nos artigos 33 e 28, ambos da Lei de Drogas, e, ademais, considerando-se, por sua vez, que o artigo 28 da Lei de Drogas traz a especificação do dolo, consistente na posse da droga para consumo pessoal, a única forma de estremar as condutas, indubiosamente diz com o desiderato mercantil, o qual não pode ser presumido, mas, ao reverso, provado, por dados objetivos que permitam inferir que a droga, de fato, destinava-se ao comércio.

Forte no princípio da presunção de inocência, sobranceiro destacar, por ocupar praça relevante, que o tráfico não pode ser presumido, ao reverso, deve ser demonstrado por elementos de convicção, que, de forma resoluto, arredem qualquer dúvida razoável.

Como cediço, assentado o escopo para o consumo pessoal no artigo 28 da Lei de Drogas, o artigo 33, necessariamente, somente pode ser compreendido a partir do desiderato do comércio de drogas.

Em uma palavra, o arquétipo probatório, no caso vertente, não se coloca, de forma segura, a escorar que a droga apreendida se destinava a fim diverso do consumo pessoal.

Conforme gizado, o artigo 28 da Lei de Drogas acena para o elemento subjetivo, a saber, o desiderato do consumo pessoal, de tal arte que, diante de ações nucleares homólogas, a única forma de estremar a posse para consumo pessoal do tráfico, indubiosamente, diz com a prova do escopo mercantil, prova esta que, a rigor, diante do princípio da presunção da inocência cabe ao Estado.

Havendo dúvidas entre o tráfico e a posse para consumo pessoal, ou, ainda, não havendo prova segura do escopo mercantil, por evidente, observando-se a tessitura constitucional, necessariamente, deve-se optar pela interpretação mais favorável ao réu, sob pena de absoluto desdouro aos princípios constitucionais que devem servir de linha guia àqueles que interpretam os fatos, as provas e as normas jurídicas para solução de um caso concreto.

Diante do cenário posto, não havendo base empírica para condenação pela prática de traficância, deve-se optar pela versão mais favorável ao réu, como única forma de

harmonização aos ditames dimanados do princípio da presunção da inocência.

Em uma palavra, em matéria penal, diante dos influxos dos princípios que deitam raízes na Constituição da República, não se pode presumir contra o indivíduo e contra a liberdade humana.

A prova de um fato, em última análise, importa na demonstração racional no sentido de que, à luz dos elementos concretos de convicção, - colhidos em juízo - prova judicializada, racionalmente, é possível aceitar que determinado fato ocorreu tal qual descrito.

No caso em apreço, não existem elementos seguros a confirmar a hipótese descrita na exordial acusatória, de tal arte que, diante deste cenário, o único desfecho possível é a absolvição do réu.

Nessa ordem de ideias, o desfecho deve ser absolutório.

Por sua vez, na quadra atual, conforme já sublinhado em outra sede, após refletir, com maior vagar, sobre a questão posta, pensamos que, indemonstrado o tráfico, não há como condenar pela posse de droga para consumo pessoal se dita narrativa não se encontra insculpida na peça acusatória, sob pena de ofensa à correlação que deve existir entre a acusação e a sentença.

Dito de outro modo, ao cabo da instrução se, diante dos elementos colhidos, divisa-se que não há indicativos do tráfico, e sim da posse, mister o aditamento da denúncia, sob pena de, ao final do processo, sem aditamento, portanto, sem imputação específica, o réu ser condenado por pretensão acusatória não contida na denúncia.

Deveras, a sentença deve se manter dentro dos limites da pretensão acusatória deduzida na denúncia, razão pela qual, ao cobro da instrução, se a quadra probatória indicar que o delito praticado não é o de tráfico, mister o aditamento pelo órgão ministerial, sob pena de o réu ser condenado por pretensão diversa daquela deduzida na denúncia, havendo, assim, um descompasso entre a imputação e a sentença.

Não desconhecemos entendimentos diversos acerca da possibilidade da desclassificação, remetendo-se ao juízo competente.

Contudo, hodiernamente, quer-nos parecer que o entendimento que empalma que não havendo prova do tráfico, e, por sua vez, não havendo aditamento, diante do princípio da correlação, deve-se palmilhar o caminho da absolvição, nos parece o mais escorreito.

Com efeito, colhe-se da obra de Aury Lopes Jr. : "Como adverte Badaró, do ne procedat iudex ex officio deriva que o juiz não pode prover sem que haja um pedido e, como consequência, daí decorre outro princípio : o juiz não pode prover diversamente do que lhe foi pedido." Direito Processual Penal, 17ª Edição, p.968.

No mesmo toar, colhe-se da obra de Aury Lopes JR, ao fazer alusão a ARAGONESES ALONSO, o seguinte trecho: "Destacamos no conceito de ARAGONESES ALONSO, anteriormente citado, a necessidade de identidade entre a decisão e o que foi "debatido", pois, para além do foi "pedido", há que se ter sempre presente o necessário contraditório e a defesa" Direito Processual Penal, Saraiva Jur, 18ª Edição, p.984.

Havendo acusação por tráfico, não se cogita da condenação por tipo penal diverso, sem o devido aditamento.

Com fulcro nos fundamentos expendidos, e, outrossim, por força do princípio da correlação entre acusação e sentença, a qual interdita a inovação judicial acerca dos fatos e imputações contidas na denúncia, julgo improcedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia para absolver VITOR PAULO BORGES, com fincas no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, caso ainda não tenha sido providenciado, determino a destruição da droga apreendida, oficiando-se a autoridade policial, nos termos do artigo 72 da Lei de Drogas.

No que se refere aos valores apreendidos, diante da absolvição, deverão ser restituídos ao seu titular.

Diante da absolvição, como corolário, expeça-se, com urgência, o abalizado alvará de soltura clausulado, garantindo-se, por conseguinte, a alforria do réu se por outro motivo não estiver preso.

P.I.C.

Jales, 15 de junho de 2022.

Fábio Antonio Camargo Dantas

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA